Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

Processo: 0817129-84.2014.8.12.0001
Autos: Procedimento Comum Cível
Autor: BRIGIDO FREITA LESMO
Réu: CASSEMS - Caixa de Assistência dos Servidores do Estado do Mato Grosso do Sul

Vistos, etc.

Trata-se de *Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Perdas e Danos* movida por **Brígido Freitas Lesmo, representado por sua Curadora Durvalina Teixeira de Almeida Lesmo** em face de **CASSEMS – Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul**, ambos já qualificados nos autos.

O autor alega que é interditado e que, na condição de funcionário público estadual, pactuou de forma compulsória o atendimento médico através de convênio com a requerida, no qual esta se comprometeu a prestar ao requerente assistência médico-hospitalar de natureza clínica e cirúrgica, mediante o pagamento de mensalidade pré-fixada, efetivado através de descontos mensais na remuneração do autor, que é policial militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

Neste sentido, aduz que no ano de 2013, necessitou realizar uma cirurgia na coluna, eis que era portador de lombociatalgia e lombalgia com protusão discal e instabilidade segmentar L5-S1, sendo que a ré somente autorizou o procedimento cirúrgico, mediante a assinatura de um termo de reconhecimento e confissão de dívida no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), firmado em 25/04/2013, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 182,08 (cento e oitenta e dois reais e oito centavos), iniciando em 10/05/2013 e terminando em 11/04/2016.

Afirma, no entanto, que o referido contrato foi firmado pelo autor, sem a assistência de sua curadora, sendo nulo em decorrência da incapacidade da parte. Assevera, ainda, que a contratação é nula, porquanto as próteses necessárias a cirurgia são de responsabilidade de plano de saúde.

Destaca que chegou a pagar duas parcelas do referido contrato, mas que interrompeu os pagamentos por entender que a dívida era indevida, sendo certo que, por conta disso, a ré bloqueou o plano de saúde, situação esta que vem causando danos ao autor.

Requer, assim:

- concessão de liminar, para determinar ao réu que cesse imediatamente a cobrança da importância de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), bem como se abstenha de praticar sanções administrativas relativas ao Plano de Saúde, decorrente do contrato de confissão de dívida, firmado em 25/04/2013, parcelados em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 182,08 (cento e oitenta e dois reais e dois centavos), bem como que não sofra nenhuma penalidade de atendimento do plano de saúde decorrente da referida dívida;

- procedência do pedido, confirmando-se a tutela de urgência, para declarar a inexistência da dívida de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), bem como se abstenha de sanções administrativas decorrentes da presente ação e do contrato firmado entre as partes, bem como autorizar todos os atendimentos médico-hospitalar

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

a serem realizados em laboratório/hospitais conveniados CASSEMS para o autor e seus dependentes;

- condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais;

- condenação da ré em devolver os valores pagos em dobro das parcelas pagas do contrato de confissão de dívida;

- benesses da justiça gratuita.

O feito, inicialmente, foi distribuído junto à 15ª Vara Cível Residual desta Comarca, tendo aquele Juízo, à fl. 58, declinado de sua competência e determinado a redistribuição do feito.

O feito foi redistribuído a este Juízo, sendo que às fls. 72/73 fora anexado Parecer Ministerial, opinando pelo deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Às fls. 74/77, foram deferidas as benesses da justiça gratuita em favor do autor e deferiu-se a tutela de urgência pleiteada na inicial. Inverteu-se o ônus da priva e determinou-se a citação da ré.

Citada, a ré apresentou contestação de fls. 83/146, alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir, uma vez que o autor não demonstra que a ré recusou atendimento ao mesmo ou efetuou bloqueio do plano de saúde. Ainda em preliminar, aduz que há prevenção da 15ª Vara Cível Residual, ante a existência de ação análoga, que abrange o conflito e crise processual instaurada nos presentes autos. No mérito, alega que, embora o autor diga que seu plano de saúde está bloqueado, não prova tal condição. Afirma, ainda, que o autor confessa que está inadimplente com a co-participação, o que, por certo, autoriza a cobrança. Aduz, ainda, que o autor é contumaz no ajuizamento de ações contra a ré, e vem se beneficiando de ordem judicial para o desbloqueio e continuidade de seu atendimento, não havendo que se falar em interrupção dos serviços por parte da ré, vez que a mesma está impedida de suspender o contrato firmado com o autor. Ademais, destaca que já é consenso na CASSEMS que, havendo contribuição mensal do associado titular, não se procede bloqueio e nem suspensão de atendimento, tanto que o autor efetuou várias consultas e exames, utilizando-se do plano de saúde. Conta que o autor aderiu à CASSEMS em 16/08/2001, usufruindo, desde então, da assistência à saúde promovida pela ré. Afirma que somente em 28/10/2010, tomou ciência de que o autor era pessoa incapaz, representado por curadora. Ressalta, entretanto, que mesmo com a descoberta da curatela, não se pode assegurar e nem garantir que o autor não mais pratique atos perante o plano de saúde. Aliás, afirma, neste sentido, que o beneficiário, de maneira costumeira, comparece e solicita a autorização de procedimentos e faz requerimentos de isenção de co-participação, e quando obtém êxito de parcelamento, ajuíza ação dizendo ser incapaz. Destaca que tudo leva a crer que o autor, mesmo sendo curatelado, transita, comparece, realiza consultas, exames e procedimentos, como pessoa normal, características que não se coadunam com uma pessoa incapaz e evidenciam a má-fé do beneficiário. Ademais, salienta que mesmo que se verifique e constate que o Termo de Confissão de Dívida foi assinado por pessoa curatelada, fato é que o autor realizou o procedimento pelo plano de saúde e que tal procedimento tem a sua respectiva co-participação, como todo evento realizado e coberto pela CASSEMS. Argumenta, ainda, que a cirurgia foi realizada independentemente do pagamento do parcelamento, o que afasta eventual alegação de imposição ou contratação mediante estado de perigo ou de necessidade. Destaca, ainda, que a cirurgia feita no autor (lombociatalgia e lombalgia L5 – S1, associado a radicular parestesia e paresia no dermatono) é eletiva,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

inexistindo urgência no procedimento e impondo-se a cobrança da co-participação. Requer a improcedência do pedido.

Intimado a apresentar réplica, o autor quedou-se inerte (fl. 243).

Intimados a indicarem as provas que pretendiam produzir, a ré pugnou pelo depoimento pessoal das partes, prova testemunhal, documental e pericial (fls. 249/250) e o autor quedou-se inerte (fl 251).

Juntada de documentos pelo réu às fls. 252/267.

O feito foi saneado às fls. 273/278, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares ventiladas pela ré. Foram fixados os pontos controvertidos. Indeferiu-se a produção de prova pericial e a tomada do depoimento pessoal do autor, vez que este é incapaz. Designou-se audiência de instrução e julgamento, para a oitiva de testemunhas.

Manifestação da ré às fls. 290/293, na qual pugna por reajustes na decisão saneadora, vez que se faz necessária a produção de prova pericial e a oitiva do autor.

Às fls. 294/295, afastou-se a impugnação da ré e manteve-se a decisão de fls. 273/278.

Termo de assentada à fl. 306, no qual constou que as partes não se compuseram. A parte ré desistiu da prova oral, o que foi homologado pelo juízo.

Parecer Ministerial às fls. 310/316, no qual opina pela improcedência do pedido.

Relatados. Decido.

Trata-se de *Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Perdas e Danos* movida por **Brígido Freitas Lesmo, representado por sua Curadora Durvalina Teixeira de Almeida Lesmo** em face de **CASSEMS – Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul**, ambos já qualificados nos autos.

1 – Das Regras Aplicadas ao Caso

Em regra, em se tratando de contrato de plano de saúde, tem-se, com base na Súmula n. 469 do STJ[1], que devem incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Contudo, é certo que a recente Súmula 608 do STJ, de 11.04.2018, prevê a inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

Neste sentido, vê-se através do Estatuto da requerida CASSEMS, constata-se que a mesma atua na modalidade autogestão, razão pela qual, inaplicável do CDC. Confira-se:

> "*Art. 1º. A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul é pessoa jurídica de direito privado, associação civil de fins assistenciais não lucrativos, na*

[1] "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." (Súmula 469, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 06/12/2010).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

> *modalidade de autogestão, constituída em Assembleia Geral de 16 de fevereiro de 2001, com sede na Rua Antonio Maria Coelho, 6.065, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, passando a utilizar a abreviatura CASSEMS como sua marca.*"

Nesse sentido, confira-se ementa prolatada pelo E. TJMS:

> *APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – PLANO DE SAÚDE SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – RECURSO PROVIDO. (...). 3.* ***Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.". (...)*** *(TJMS. Apelação n. 0842689-62.2013.8.12.0001, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 27/03/2018, p: 09/04/2018).*

Assim, em aplicação ao disposto na Sumula 608 do STJ, tem-se que ao presente caso não incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mas sim as regras previstas no Código Civil de 2002, vez que inexiste relação de consumo entre as partes.

2 – Da Alegação de Inexistência de Débito

No caso em apreço, o autor alega que, no ano de 2013, necessitou realizar uma cirurgia na coluna, eis que era portador de lombociatalgia e lombalgia com protusão discal e instabilidade segmentar L5-S1, tendo a ré somente autorizado o procedimento cirúrgico, mediante a assinatura de um termo de reconhecimento e confissão de dívida no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), firmado em 25/04/2013, dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 182,08 (cento e oitenta e dois reais e oito centavos), iniciando em 10/05/2013 e terminando em 11/04/2016.

Afirma, no entanto, que o referido contrato foi firmado pelo autor, sem a assistência de sua curadora, sendo nulo em decorrência da incapacidade da parte. Assevera, ainda, que a contratação é nula, porquanto as próteses necessárias a cirurgia são de responsabilidade de plano de saúde.

De fato, assiste razão ao autor, impondo-se a procedência do pedido, senão vejamos.

Como dito alhures, requer a parte autora a anulação do termo de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

confissão de dívida de fl. 33/35, firmado entre as partes, sob a alegação de que, no momento em que firmou o contrato, não possuía plena capacidade para prática dos atos da vida civil.

De acordo com Miguel Maria de Serpa Lopes:

> *"Os elementos estruturais do negócio jurídico podem ser vistos sob os seguintes pontos de vista: a) quanto aos requisitos da conclusão do negócio jurídico, compreendendo a capacidade de celebrar negócios jurídicos, a declaração de vontade, a ausência e vícios de vontade, o fenômeno da representação; b) quanto ao seu conteúdo, envolvendo o estudo dos elementos do negócio jurídico em geral; c) em relação à sua ineficácia, compreendendo a nulidade, a anulabilidade e os meios de convalidação; d) finalmente, quanto à sua interpretação[2]".*

Extrai-se, portanto, que capacidade civil do agente é um dos requisitos essenciais para a formalização de um negócio jurídico. O Código Civil, neste sentido, em seu art. 104, elenca os requisitos essenciais para a formalização de um negócio jurídico válido, incluindo, dentre eles, a capacidade do agente:

> *"A validade do negócio jurídico requer:*
> ***I- agente capaz;***
> *II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;*
> *III- forma prescrita ou não defesa em lei."*

Constatada a incapacidade do agente, o negócio é nulo, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.

> *"É nulo o negócio jurídico quando:*
> ***I- celebrado por pessoa absolutamente incapaz;***
> *II- foi ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;*
> *III- o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;*
> *IV- não revestir a forma prescrita em lei;*
> *V- for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;*
> *VI- tiver por objetivo fraudar lei imperativa;*
> *VII- a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."*

Em complemento à norma supracitada, o art. 3º, do Código Civil, por sua vez, apresenta um rol de pessoas que são consideradas incapazes absolutamente pelo nosso ordenamento jurídicos:

"I- os menores de dezesseis anos;

[2] LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil: Introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. Volume I. 9ª ed. Rev. E atual. Ed. Freitas Bastos. Rio De Janeiro, 2000 – fls. 427/428.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

> *II- os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;*
> *III- os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade".*

Constatando-se que uma das pessoas arroladas no art. 3º, do CC/2002 realizou negócio jurídico, sem que estivesse devidamente representado, o negócio será anulado, por ausência de requisito essencial, nos termos do art. 3º c/c art. 104, I c/c art. 166, I, do CC/02.

No caso em apreço, não há dúvidas de que o termo de confissão de dívida de fl. 33/35, no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), datado de 25/04/2013, é nulo, porquanto assinado por pessoa absolutamente incapaz (sem a anuência do seu respectivo curador), o que por certo inviabiliza a cobrança daquela dívida.

Neste sentido, verifica-se que, na data dos fatos, o autor já não poderia assinar contratos e/ou termos perante a ré, porquanto, nos termos da sentença prolatada nos autos n. 001.09.036484-9, que tramitou perante a 3ª Vara de Familia desta Capital, fora declarado absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada Curadora (Sra. Durvalina Teixeira de Almeida Lesmo), conforme termo de curatela datado de 04/11/2009 (ou seja, anterior à dívida aqui objurgada), sendo nulo os contratos firmados após tal data.

É o que diz o E. TJRS:

> *"(...) NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE CIVIL. INTERDIÇÃO.* ***Considera-se nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, sem representação do seu representante legal ou autorização judicial, ex vi legis do art. 166, I, do CC. No caso dos autos, a incapacidade do autor era preexistente ao contrato celebrado com o Banco, razão pela qual é nulo o negócio jurídico celebrado sem a representação da curadora. Reconhecida a nulidade do contrato, a situação deverá retornar ao \"status quo ante\", com a restituição dos valores eventualmente já adimplidos.*** *PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA E APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068797117, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 31/05/2016)."*

E não há que se falar que a ré não tinha conhecimento da incapacidade civil do autor, **vez que reconheceu, em sua contestação, que na data de 28/10/2010** (*e, portanto antes da assinatura do termo de confissão de fl. 33/35 – 25/04/2013*) t**omou ciência da condição psíquica do requerente e da existência de nomeação de curador para o mesmo,** evidenciando, pois, sua negligencia em firmar contrato com pessoa incapaz, sem observar as devidas cautelas.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

Para tanto, colaciona-se trecho da contestação:

> *"Somente 28/10/2010, quando se preparava para discutir judicialmente a primeira COPARTICIPAÇÃO, compareceu a CURADORA informando ser a responsável pelo associado titular, juntando o TERMO DE CURATELA.*
> *Nesta oportunidade a CURADORA JUNTOU TERMO DE CURATELA EM PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA EMISSÃO E OBTENÇÃO DE CÓPIA DO TERMO DE ADESÃO E EXTRATO DE UTILIZAÇÃO DO AUTOR, que lhe foi deferido e entregue."* (fl. 107).

Ademais, não merece prosperar a alegação de que não se sabe o grau de incapacidade do autor e que não se deve deduzi-lo incapaz para todos os atos da vida civil. Primeiro, porque a sentença prolatada nos autos n. 001.09.036484-9, foi clara em determinar a incapacidade absoluta do requerente; e segundo, porque não cabe a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência ao presente caso, vez que tal norma ainda não havia sido publicada quando da assinatura do termo de confissão de dívida de fls. 33/35, objurgado nos autos.

Assim, reconhecida a incapacidade absoluta do autor e a ausência de anuência de sua curadora, impõe-se o reconhecimento da nulidade do termo de confissão de dívida de fls. 33/35, no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme mandamenta o art. 166, I, do Código Civil.

E ainda que se admita que a Curadora do autor anuiu tacitamente àquela confissão de dívida, e que não seria o caso de nulidade por incapacidade das partes, na há que se falar em improcedência do pedido, uma vez que é certo que a dívida ali exposta é nula por contrariar a legislação em vigor, senão vejamos.

No caso em tela, verifica-se, através do art. 10 do Estatuto da requerida (fl. 150), que: "*(...) São deveres fundamentais do Associado Titular e dos Participantes: (...) e) arcar com franquia e os custos da co-participação financeira estabelecida pelo Conselho de Administração sobre os serviços assistenciais prestados pela CASSEMS.".*

De fato, é possível a cobrança de fator de co-participação em face da associada/autora. No entanto, a referida cobrança não poderá recair sobre serviços e utensílios essenciais para o sucesso da intervenção médica. É o que dispõe o art. 10, VII, da Lei 9.656/98:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(...)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

Deste modo, tem-se que a interpretação do referido dispositivo é de que a cobrança de órtese e prótese só é admitida quando tais objetos não estiverem associados ao ato cirúrgico, sendo vedada a cobrança de qualquer equipamento essencial ao tratamento médico, restando abusiva qualquer cláusula que estabeleça o contrário.

É o que diz o E. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. PROIBIÇÃO DO FORNECIMENTO DE PRÓTESE PARA CIRURGIA DE JOELHO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA STF/283. CLÁUSULA ABUSIVA. CARACTERIZAÇÃO. 1.- Analisando o contrato firmado entre as partes, concluiu o Tribunal de origem pela abusividade da cláusula que excluía de cobertura o uso de prótese, considerada essencial ao procedimento clínico realizado, por violação do artigo 51, IV,do Código de Defesa do Consumidor. 2.- Esse fundamento, suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado, não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3.- Ademais, segundo o entendimento deste Tribunal, "se a colocação de próteses é necessária para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura." (REsp 811.867/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 22.4.10). 4.- Agravo Regimental improvido". (AgRg no AREsp 259.570/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013) "

O E. TJMS também adota este posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PLANO DE SAÚDE DA CASSEMS – EXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ROL EXEMPLIFICATIVO - FATOR DE COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DE COBRANÇA NO REGULAMENTO DO PLANO DE SAÚDE OU EM RESOLUÇÃO DA ANS – RECURSO CONHECIDO E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

> *NÃO PROVIDO. Se a escolha da prótese provém do médico que assiste o paciente com demonstração da necessidade para o tratamento cirúrgico autorizado pela CASSEMS, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura em detrimento de existir outra com custo operacional mais baixo.* ***Incumbe à requerida o ônus de comprovar que no Regulamento do Plano de Saúde ou nas Resoluções Normativas da ANS havia previsão de cobrança da coparticipação em relação aos materiais utilizados em procedimento cirúrgico. Diante da ausência de prova quanto à existência de previsão legal para a cobrança da coparticipação, não há como admitir tal exigência do usuário do plano de saúde.*** *(TJMS. Apelação Cível n. 0839840-20.2013.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 26/06/2019, p: 28/06/2019)*".

Neste sentido, verifica-se, na hipótese em apreço, que o autor (beneficiário do plano de saúde requerido – fl. 30), obteve a autorização da ré para a realização de procedimento cirúrgico, consubstanciado em "*Artrodese da Coluna c/ Instrumentação por Segmento*", conforme ofício/CASSEMS n. 16674/2013, 16673/2013 e 16038/2013 de fl. 38/39 e 42, datado de abril e maio/2013, sendo que os materiais cirúrgicos utilizados naquele procedimento totalizaram o montante de R$ 23.315,00 (vinte e três mil e trezentos e quinze reais), sendo que, em decorrência da referida cirurgia, o autor comprometeu-se ao pagamento de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), em favor da ré, a título de coparticipação, conforme termo de reconhecimento e confissão de dívida de fl. 33/35.

Nota-se, pois, que a cobrança efetuada pela ré em face do autor foi a título de co-participação, referente a custeio de material a ser utilizado em intervenção cirúrgica, o que, como visto na presente sentença, não se compatibiliza com o art. 10, VII, da Lei 9.656/98, restando evidente a ilegalidade da referida cobrança.

É este o entendimento adotado pelo E. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREPARO – AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – CASSEMS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO EM 30% DOS CUSTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ÓRTESE, PRÓTESE E SEUS ACESSÓRIOS – ABUSIVIDADE – NULIDADE DAS COBRANÇAS E TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) É abusiva a norma que imponha ao usuário o pagamento de 30%*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

> *dos custos de aquisição dos materiais e órtese, prótese e seus acessórios, quando são inerentes ao próprio ato cirúrgico e, por consequência, é nulo todos os Termos de Reconhecimento e Confissão de Dívida por Terceiro garantido por Nota Promissória (art. 51, IV, § 1º, III, do CDC). O usuário tem direito de ser ressarcido pelos valores indevidamente pagos ao plano de saúde, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)" (TJMS - AC 0826322-60.2013.8.12.0001 – 3ª Câmara Cível – Rel. Exmo. Sr. Des. Eduardo Machado Rocha – Julg. 02/12/2014).*

Ademais, o próprio ofício/CASSEMS n. 38/39 e 42, indica que o valor cobrado do autor era para o custeio dos materiais a serem utilizadas no ato cirúrgico a ser efetuado no mesmo, quais sejam: "*cage lombar em peek (dispositivo intersomático de manutenção de espaço intervertebral, campo operatório adesivo iodoforado (ioban), drill pneumático e brocas (incluso fresas para craniotomo), enxerto ósseo hidroxiapatita, haste longitudinal para associação com parafusos em titânio, kit monitorização neurofisiológica intra-operatória, parafusos associáveis a haste (tipo pediculares, poliaxiais em titânio), sistema fixação transversal crosslink em titânio, manta térmica*", os quais eram imprescindíveis para a cirurgia de Artrose da Coluna c/ Instrumentação por Segmento, consoante guia de requerimento assinado por médico (fls. 43).

Ademais, a própria ANS, através de informações contidas em seu sítio "*http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/materiais_implantaveis.Pdf*", indica quais são os materiais que devem ser custeados pela operadora de plano de saúde (implantáveis), sendo estes os mesmos arrolados no ofício de fl. 38/39 e 42, o que evidencia que os materiais cobrados do autor, eram para utilização em ato cirúrgico.

Ademais, é inadmissível que haja a limitação de cobertura pela requerida, ainda que na forma de cobrança de co-participação, uma vez que a Resolução Normativa nº 211/2010/ANS, vigente à época da cobrança (25/04/2013 – conforme termo de reconhecimento e confissão de dívida – fl. 33/35), estabeleceu, no art. 16, §1º, VIII, que no plano referência podem ser excluídos da cobertura do plano de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, **desde que não ligados ao ato cirúrgico,** não se tratando do caso em tela, uma vez que o procedimento cirúrgico buscado pelo autor era justamente a colocação de próteses na lombar, tornando ilícita a cobrança perpetrada pela ré.

Neste sentido, eis o art. 16, §1º, VIII, da Resolução Normativa nº 211/2010/ANS:

> *"Art. 16 - A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998.*
>
> *§1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais previstas no **artigo 10** da Lei nº 9.656, de 1998:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

VIII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;"

Convém ressaltar também que, ainda que a ANS admitisse a cobrança do referido procedimento, é certo que a requerida não demonstrou que a cirurgia realizada no requerente (Artrodese da Coluna c/ Instrumentação por Segmento) não estava inclusa na cobertura contratual, ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ora, o contrato de fls. 238/239 não revela qualquer possibilidade de cobrança de co-participação nos materiais utilizados em procedimento cirúrgico, deixando evidente que a parte ré cobrou quantia que não possuía previsão no contrato firmado entre as partes.

Além disso, ao apresentar a sua contestação, anexou ao feito tão somente o seu Estatuto (fls. 152/170), o qual, embora preveja o dever de pagamento de coparticipação ao beneficiário (ora autora), não estabelece que tal obrigação também incide nos materiais utilizados em procedimento cirúrgico, não havendo qualquer respaldo para a cobrança feita pela ré, restando evidente a conduta ilícita.

Assim, demonstrada a ilicitude da ré, a qual efetuou cobrança indevida em face do autor (*seja porque fundou-se em contrato nulo de pleno direito, pois firmado por pessoa absolutamente incapaz, seja por que cobrou pela utilização de materiais em procedimento cirúrgico, o que é vedado, conforme reconhecido na presente sentença*), impõe-se a procedência do pedido, para o fim de declarar nulo o termo de reconhecimento e confissão de dívida de fl. 33/35, no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), datado de 25/04/2013.

3 – Da Repetição do Indébito

O autor, em sua inicial, pleiteia a restituição dos valores pagos em favor da ré, em decorrência do termo de reconhecimento e confissão de dívida (fl. 33/35), o qual foi declarado nulo na presente sentença.

No que tange ao dano material, sabe-se que a indenização mede-se pela extensão do dano. Essa é a regra estabelecida pelo artigo 944, caput, do Código Civil, que consagra importante função do instituto de responsabilidade civil, que é recompor a lesão sofrida pela vítima, na extensão do prejuízo que lhe foi causado. Portanto, havendo alegação de prejuízo patrimonial, deve ser averiguada qual a extensão da perda, o que, no presente caso, deve ser feito através da apreciação da prova documental apresentada.

No caso em tela, verifica-se que a requerente demonstrou a ocorrência de conduta ilícita da requerida, consubstanciada na cobrança indevida em face do autor, conforme restou reconhecido na presente sentença, no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais) divididos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 182,08 (cento e oitenta e dois reais e oito centavos), cada uma, com primeiro vencimento em 10/05/2013, conforme termo de reconhecimento e confissão de dívida de fl. 33 e solicitação de parcelamento de fl. 34/35.

Contudo, em que pese a cobrança indevida, não restou evidenciado qualquer pagamento indevido por parte do autor, razão pela qual não há que se falar em

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

repetição do indébito.

Ademais, é certo que o boleto anexado à fl. 36 em nada comprova o suposto pagamento indevido feito pelo autor, pois desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento.

Deste modo, ausente a prova do prejuízo material, impõe-se a improcedência do pedido, neste particular.

4 – Dos Danos Morais

A Constituição Federal de 1988, ao fixar os direitos e garantias fundamentais, instituiu o direito à indenização por danos morais em seu art. 5º, incisos V e X.

Regulamentando tal direito, estabelece o artigo 186 do Código Civil que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Em complemento, o art. 927 do Código Civil prescreve que: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo."

Desse modo, conjugando tais dispositivos, aquele que causar dano a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a repara-lo. Entretanto, é certo que para vislumbrar tal responsabilidade é imprescindível a coexistência de três elementos fundamentais, quais sejam, o dano sofrido pela vítima, a conduta ofensiva praticada pelo agente e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta praticada.

Compulsando a exordial, verifica-se que a autora pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por esta, sem justo motivo, ter-lhe efetuado a cobrança indevida de valores e, ainda, suspendido os serviços do plano de saúde pelo inadimplemento das parcelas do termo de confissão de dívida de fls. 33/35, declarado nulo nesta sentença.

O pedido, contudo, não merece procedência, senão vejamos.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que, nos casos de negativa de cobertura de plano de saúde ou de seguro saúde, o dano moral é in re ipsa, mesmo sendo inadimplemento contratual.

Eis julgado nesse sentido:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.*
> *1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "conquanto geralmente nos contratos o mero inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp 735.168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008).
[...]
3. Para fixação do quantum indenizatório, tendo em mira os interesses jurídicos lesados (direito à vida e direito à saúde), tenho por razoável que a condenação deve ter como valor básico R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não destoando da proporcionalidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta Corte.
4. No que tange à segunda fase do método bifásico, para a fixação definitiva da indenização, partindo do valor básico anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: a) trata-se de caso envolvendo consumidor hipossuficiente litigando contra sociedade empresária de grande porte; b) o ato ilícito praticado pela ora recorrida e que deu ensejo aos danos morais suportados pela recorrente relaciona-se à graves problemas de saúde decorrentes de acidente automobilístico, demandando a recorrente de tratamento fonoaudiólogo de urgência para a recuperação da capacidade de mastigação e deglutição; c) a recusa à cobertura das despesas relacionadas às sessões de fonoaudiologia inviabilizaria o próprio tratamento médico, impedindo, a rigor, a utilização de meio hábil à cura e inviabilizando a própria concretização do objeto do contrato.
5. Indenização definitiva fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)".

Ocorre que, na hipótese em apreço, ainda que a ré tenha efetuado cobrança indevida em face do autor, é certo que não houve a negativa de atendimento para com este, tanto que a cirurgia prescrita por seu médico fora realizada, sem que este tenha efetuado o pagamento integral do termo de confissão de dívida de fls. 33/35, fato este incontroverso nos autos.

Além disso, ainda que o autor alegue que a ré suspendeu os serviços médicos oriundos do plano de saúde objurgado nos autos, não comprovou sua alegação, ônus

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Neste sentido, o histórico de fls. 219 evidencia que, ao contrário do que consta na inicial, todos os tratamentos pleiteados pelo autor, durante o período de junho a agosto/2014, foram devidamente prestados pela ré, não havendo que se falar em negativa injustificada por parte da requerida ("autorizado).

Além disso, não fora anexado ao feito qualquer elemento probatório que revelasse que o requerente teve alguma consulta e/ou exame cancelado, a fim de embasar suas alegações, nos levando a crer que a ilicitude da ré restringiu-se à cobrança indevida, inexistindo qualquer negativa de tratamento médico ao autor.

Ressalta-se que fora dada oportunidade para que o autor comprovasse suas alegações (fl. 246), tendo o mesmo quedado-se inerte (fl. 251), revelando sua inércia probatório e evidenciando que a situação, embora ilícita, não acarretou em prejuízo moral à este.

Deste modo, inexistindo provas do prejuízo moral suportado, impõe-se a improcedência do pedido, neste particular.

Dispositivo

Posto isto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, rejeito o Parecer Ministerial e julgo, com resolução do mérito, PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por **Brígido Freitas Lesmo, representado por sua Curadora Durvalina Teixeira de Almeida Lesmo** nesta AÇÃO movida em face de **CASSEMS – Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul**, para o fim de:

I) julgar procedente o pedido, para o fim de declarar inexistente o débito oriundo do termo de reconhecimento e confissão de dívida de fl. 33/35, no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), datado de 25/04/2013;

II) julgar improcedente o pedido formulado na inicial, referente à repetição do indébito;

III) julgar improcedente o pedido formulado na inicial, referente à indenização por danos morais.

Ante o teor da presente sentença, ratificar parcialmente a tutela de urgência concedida às fls. 74/77, apenas no que tange ao dever da ré abster a efetuar cobranças em face do autor, decorrente do tempo de confissão de dívida de fls. 33/35. Deixo de ratificar a parte em que determina o imediato desbloqueio do cartão do plano de saúde do autor, vez que, conforme fundamentação exposta, jamais houve a suspensão dos serviços da ré.

Ante a sucumbência, condeno o autor (na proporção de 70% - setenta por cento) e a ré (na proporção de 30% - trinta por cento), pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Anote-se que tal verba fica diferida, nos termos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
4ª Vara Cível Residual

do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fl. 75).

Certificado o trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Campo Grande-MS, *data da assinatura digital*.

Vania de Paula Arantes
Juiz(a) de Direito

Assinado por Certificação Digital

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VANIA DE PAULA ARANTES, liberado nos autos em 16/07/2019 às 14:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0817129-84.2014.8.12.0001 e código M0PxJxD1.